

1500746-82.2020.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Reside em Jacareí. Está preso por tráfico de drogas pelo qual foi condenado. Já respondeu, também, por outro processo por crime de tráfico de drogas, onde foi preso com seu irmão. Trabalha na feira.

Na espécie, a negativa do réu ficou isolada nos autos ao ser confrontada com as demais provas produzidas durante a regular instrução do feito.

A testemunha BRUNO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500746-82.2020.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500746-82.2020.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2136273/2020 -

DISE- DEL.SEC.JACAREI, 11730277 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 53/20/502 - DISE-

DEL.SEC.JACAREI, 2136273 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 2136273/2020 - DISE-

DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL APARECIDO OLIVEIRA DUARTE FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.RAFAEL APARECIDO OLIVEIRA DUARTE FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. art. 61, inc. II, "j", do Código Penal, porque, no dia 04 de junho de 2020, por volta das 10h00min, na Avenida dos Migrantes, 709, Parque Meia Lua, nesta cidade e comarca, o acusado, agindo em ocasião de calamidade pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, as

seguintes drogas: 09 invólucros de cocaína.

Após o recebimento da denúncia (fls. 124/127), o réu foi devidamente citado e apresentou defesa preliminar (fls. 167/168).

Durante a instrução foram ouvidas quatro testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Dr. Promotor de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia e respectivo aditamento. A Douta Defesa, por seu turno, alegou inicialmente ser a prova nula em razão da atuação ilícita neste caso dos Guardas Civis Municipais, a ensejar a absolvição do réu. Subsidiariamente requereu a desclassificação da conduta inicial para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. No caso de condenação pelo crime apontado na exordial a pena deverá ser estabelecida no patamar mínimo, aplicando-se a causa de redução da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar máximo, a qual deverá ser substituída nos termos do artigo 44, do Código Penal, estabelecendo, ainda, o regime inicial aberto, facultando-se o apelo em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/06), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11), Laudo de Constatação provisória de substâncias entorpecentes (fls. 17/18), bem como pelo Laudo Definitivo de substâncias entorpecentes (fls. 109/111), que constatou tratar-se, efetivamente, de substância entorpecente (cocaína).

A autoria restou igualmente comprovada.

O réu RAFAEL APARECIDO OLIVEIRA DUARTE FERREIRA permaneceu em silêncio durante a fase extrajudicial. Em juízo, ao ser interrogado, o réu negou o crime, aduzindo que as drogas apreendidas eram destinadas ao seu próprio consumo. Iuri provavelmente ficou assustado e acabou prestando o depoimento na fase policial. É usuário de cocaína deste os quatorze anos. Atualmente tem 20 anos de idade. Reside em Jacareí. Está preso por tráfico de drogas pelo qual foi condenado. Já respondeu, também, por outro processo por crime de tráfico de drogas, onde foi preso com seu irmão. Trabalha na feira.

Na espécie, a negativa do réu ficou isolada nos autos ao ser confrontada com as demais provas produzidas durante a regular instrução do feito.

A testemunha BRUNO FREITAS DOS SANTOS PEREIRA, Guarda Municipal, declarou que na data dos fatos realizava ronda pelas escolas municipais de motocicleta juntamente com seu colega de serviço GCM Jordache, pelo bairro Parque Meia Lua, na Av. dos Migrantes, altura do numeral 709, quando avistaram o implicado Rafael Aparecido Oliveira Duarte Ferreira juntamente com a pessoa de Yuri Haro, em atividade típica de venda de drogas. Yuri entregava certa quantia em dinheiro ao acusado Rafael. Diante das suspeitas, resolveram abordá-los, ocasião em que ambos tentaram correr, mas foram abordados logo em seguida. Rafael dispensou um saco plástico contendo em seu interior 09 pinos de cocaína e a quantia de R\$ 62,00 reais. Com relação a Yuri nada de ilícito fora encontrado em seu poder, mas ele confirmou, no entanto, que tinha acabado de entregar a quantia de R\$20,00 reais ao acusado com o intuito de adquirir um pino de cocaína, venda esta não concretizada por conta da abordagem.

No mesmo sentido o depoimento do Guarda Municipal JORDACHE HENRIQUE DE LIMA, que

participou da prisão do acusado, confirmando toda a diligência, especificamente a dinâmica da abordagem. O acusado estava acompanhado de Iuri, que estava comprando drogas do acusado. O acusado e Iuri foram abordados juntos. O acusado se preparava para entregar a droga ao comprador no momento da abordagem.

A testemunha IURI MIRANDA HARO, declarou em solo policial que é usuário de drogas há 07 anos e na data dos fatos encontrava-se na Av. dos Migrantes com intuito de adquirir um pino de cocaína, ocasião em que se aproximou do implicado Rafael Aparecido Oliveira Duarte Ferreira, entregou a ele a quantia de R\$ 20,00 e solicitou um pino de cocaína. Rafael estava com uma sacola nas mãos e antes de receber o pino de cocaína foram abordados por Guardas civis. Nada foi localizado em seu poder. Foi a primeira vez que pretendia adquirir droga de Rafael, pois só o conhecia de vista. Em juízo, Iuri declarou que não se recordava muito bem dos fatos, mas declarou ser usuário de drogas e estava no local para adquirir entorpecentes.

Pois bem.

De início rejeito a alegação veiculada pela Douta Defesa de nulidade do processo por não vislumbrar, neste caso, qualquer irregularidade na conduta dos Guardas Municipais que atuaram na ocorrência e prenderam em flagrante o acusado.

Não houve violação ao artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, que estabelece: "Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei" e ao artigo 144, § 5º, do mesmo Diploma Legal, que estabelece a competência da Polícia Militar para o policiamento ostensivo.

Cabe à Polícia Militar exercer o patrulhamento ostensivo e à Polícia Civil exercer o papel investigativo, cabendo tão somente à Guarda Municipal a proteção de bens, serviços e instalações públicos.

Contudo, no caso em apreço os Guardas Municipais não efetuaram qualquer diligência para investigar ou prender um determinado traficante. Os Guardas se depararam com uma conduta que em tese caracterizaria o crime de tráfico de drogas praticado no imóvel palco dos fatos e conduziram preso em flagrante o acusado e a testemunha Iuri como testemunha.

Aliás, os GCMS presenciaram o momento em que o acusado negociava a venda de uma porção de droga para Iuri, o usuário.

A atuação da Guarda Municipal não envolveu, neste caso, patrulhamento ostensivo e judiciário. Os Guardas agiram rigorosamente nos termos da lei, na esteira do Prescreve o artigo 301, do Código de Processo Penal: "Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito".

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

No mérito, as provas produzidas são contundentes no sentido de que o réu efetivamente trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas à comercialização.

Os Guardas Municipais apresentaram depoimentos sólidos com descrição integral da diligência que culminou com a prisão do acusado no momento em que negociava a venda de drogas para a testemunha Iuri, recebendo dinheiro do mesmo.

O acusado e a testemunha Iuri, quando presenciaram a presença dos GCMS, tentaram fugir, mas acabaram sendo abordados. Durante a fuga o réu dispensou um saco plástico contendo em seu interior 09 pinos de cocaína e a quantia de R\$ 62,00

reais. Em seguida o acusado admitiu a traficância informalmente, e Iuri no ato da abordagem confirmou que estava adquirindo drogas do increpado.

Pequenas divergências nos relatos dos milicianos não comprometem a prova produzida.

Outrossim, a testemunha Yuri admitiu em seu depoimento que tinha acabado de entregar a quanguia de R\$20,00 para Rafael com o escopo de adquirir cocaína. A compra não se concretizou diante da abordagem dos guardas.

Portanto, as circunstâncias que envolveram a prisão do réu não deixam nenhuma dúvida acerca da atividade ilícita de venda de drogas por ele desenvolvida.

A condenação é de rigor, nos termos da denúncia.

3. Passo a dosimetria da pena, na forma do artigo 68, do CP.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, tendo em vista o disposto no artigo 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor fixado no mínimo.

Na segunda fase de dosimetria, não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas.

No tocante à agravante prevista no artigo 61, II, "j" do Código Penal este Magistrado vem reiteradamente afastando a sua incidência em casos semelhantes.

De fato, esta circunstância agravante não pode ser analisada de forma objetiva por si só e aplicada indistintamente para todos os crimes praticados durante a vigência do estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Dessa forma, o crime praticado pelo acusado deve ser verificado de acordo com o contexto fático, ou seja, o agente criminoso deve, de alguma forma, ter se aproveitado da situação calamitosa para a prática da infração penal.

E não vislumbro nos autos qualquer indicativo de que o réu tenha se beneficiado de alguma forma do estado de calamidade pública para a prática do ato criminoso em testilha.

Nesse sentido, cabe trazer à baila ensinamento doutrinário proferido por Cleber Masson: "Essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais mezinhos postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime" (Masson, Cleber. Direito Penal: Parte Geral. 13ª, São Paulo: Método, pág. 581).

No caso em tela, o delito poderia ter sido praticado, indiferentemente, em momento sem a calamidade pública decretada pelo Poder Público.

Na terceira fase indefiro a aplicação do benefício do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

O acusado demonstrou absoluta dedicação às atividades criminosas, especificamente tráfico de drogas. Após a prisão pelos fatos aqui tratados, onde o réu foi beneficiado com a liberdade provisória, ele foi preso novamente no mês subsequente traficando drogas e, posteriormente, no ano de 2021 também pelo crime de tráfico de drogas.

Ou seja, ao ser colocado em liberdade o acusado retomou as suas atividades criminosas.

Aliás, o réu está preso atualmente cumprindo pena por tráfico de drogas.

Infelizmente o réu não procurou um trabalho legítimo que assegurasse a subsistência de sua família após ser beneficiado com a liberdade provisória nestes autos, o que é inaceitável!

A receita diária auferida com a atividade ilícita de venda de drogas explica, certamente, a sua pouca vontade em procurar um emprego lícito e o ímpeto de retomar sua atividade "lucrativa" de venda de drogas.

Todos esses elementos inviabilizam, sem sombra de dúvidas, a redução da pena nos moldes estabelecidos pelo artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e a concessão de outros benefícios previstos na Legislação Processual Penal em vigor.

Não existem, ainda, causas de aumento de pena a serem analisadas.

Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro porque a pena cominada impede o benefício. Segundo porque as circunstâncias da prisão em flagrante do réu e o seu comportamento na sociedade, retomando a atividade criminosa pouco tempo depois, igualmente afastam a possibilidade de concessão do benefício.

O réu cumprirá a pena em regime inicial fechado, compatível com a gravidade do crime cometido, que é equiparado a hediondo e vem assolando esta região do Vale do Paraíba, com as circunstâncias da sua prisão em flagrante, e com sua personalidade demonstrada desde a sua primeira prisão em flagrante por este crime, culminando com a sua segunda prisão em flagrante no mesmo ano de 2020 pela prática do mesmo crime.

Não há motivo, portanto, para fixação de regime prisional diverso do fechado para o réu, que deve ser tratado com rigor por ter reincidido na mesma conduta criminosa ao invés de buscar uma ressocialização.

Faculto o apelo em liberdade, aventando possível discussão sobre a aplicação ou não do artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 no caso em tela e a divergência jurisprudencial no E. Tribunal de Justiça de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, mormente porque o réu era tecnicamente primário na época dos fatos.

4. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar o réu RAFAEL APARECIDO OLIVEIRA DUARTE FERREIRA a cumprir pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Decreto o perdimento do dinheiro e bens apreendidos em favor da União para posterior reversão ao FUNAD, eis que evidente produto do tráfico (art. 63, par. 1º, da lei de Drogas). Oficie-se.

Determino, ainda, o confisco dos bens apreendidos, de origem ilícita, nos termos do artigo 243, § único, da Constituição Federal de 1988.

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu e a necessária guia de recolhimento para início da fase executória.

Jacarei, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA